CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Página

1. DEFINICIÓN: ... 2

2. ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO ES? ... 2

3. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES ... 2

4. DEFINICIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES ... 3

5. LLAMADO A CONCURSO Y CONTRATACIÓN ... 3

6. CALIFICACIÓN PREVIA OBLIGATORIA DE LOS OFERENTES ... 3

7. ADJUDICACIÓN ... 3

8. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL ... 3

9. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS ... 4

10. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ... 4

11. TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ... 5

11.1. CONTRATO DE SUMINISTRO ... 5
11.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ... 5
11.3. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ... 5
11.4. CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ... 5
11.5. CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO ... 5
11.6. PERMISO PRECARIO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO ... 5
11.7. CONTRATO DE EMPRESTITO PÚBLICO ... 5
11.8. CONTRATO DE CONCESIÓN DE TIERRAS Y BOSQUES FISCALES ... 5
11.9. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA: ... 6

12. ENTES REGULADORES ... 7

12.1. ¿PARA QUE SE CREARON? ... 7

12.2. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ... 7

12.3. FUNCIONES DE LOS ENTES REGULADORES ... 8

12.4. ¿Quiénes Controlan a los Entes? ... 8

13. ARBITRAJE ENTRE GOBIERNOS NACIONALES Y EMPRESAS TRANSNACIONALES. ... 9

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE ENTES REGULADORES ... 10

ANEXO 2: ENTES REGULADORES ... 11

1. DEFINICIÓN:

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO CUALQUIER FORMA JURÍDICA (Nación, Provincia, Municipio, Entes Autónomos y/o Autárquicos, Empresas Estatales y Empresas Mixtas con participación Estatal mayoritaria) ES EL COMITENTE.
Los contratos del Estado, "contratos de la Administración o contratos administrativos", están regidos predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico específico.
Tanto la provisión de Bienes y/o Servicios tiene que ser de “UTILIDAD PÚBLICA” con el objeto de proveer al BIEN COMÚN, o sea para que la COMUNIDAD se beneficie de los mismos, De allí la prerrogativa que contempla CÁUSULAS EXORBITANTES a favor de la Administración.
Se presume que los actos ADMINISTRATIVOS que instrumentan estos contratos deben atender a los principios de TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD e IGUALDAD a través de determinados instrumentos: LICITACIÓN / REGISTROS NACIONALES DE PROVEEDORES / FORMAS.

2. ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO ES?

BILATERAL (Hay dos partes)
CONMUTATIVO (prestaciones recíprocas equivalentes)
ONEROSO (hay monto en juego)
FORMAL (lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal >>>> cédula de notificación)
CONSENSUAL (simple consentimiento)
ADMINISTRATIVO (el Comitente es la Administración Pública)

3. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES

RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA.
Las partes contratantes están en un plano desigual. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. La Administración impone ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al contratista.

Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la Administración Pública, con quien celebra un contrato, tiene su origen en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato, pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que puede afectar su ejecución.

EXISTEN CLÁUSULAS EXHORBITANTES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN (Implican privilegios a favor de una de las partes – abuso del derecho – para salvaguardar intereses generales (ej. renuncia al Derecho de Retención, no reconoce lucro cesante en caso de desistimiento unilateral, se reserva la interpretación final de los contratos, no reconoce responsabilidad precontractual)

4. DEFINICIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES

ESTADO (ADMINISTARCIÓN)		EMPRESA (PRIVADA)
COMITENTE	>>>>>>>>>>>>	CONTRATISTA, EMPRESARIO
CEDENTE	>>>>>>>>>>>>	CONCESIONARIO, LICENCIATARIO

5. LLAMADO A CONCURSO Y CONTRATACIÓN

VENTA DEL PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA (Publicación del Llamado)
EXCEPCIÓN:
- Realización de trabajos de Urgencia Reconocida (servicios o trabajos de orden social de carácter impostergable)
- Reserva o secreto de Estado. Se autoriza la contratación directa "cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva o "cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas

6. CALIFICACIÓN PREVIA OBLIGATORIA DE LOS OFERENTES

- EN CASO DE OBRA PÚBLICA: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE O. PÚBLICAS (calificación y verificación de capac Técnica, de contratación y facturación anual, índices de magnitud empresaria, acreditación de la sociedad legal)

- EN CASO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO (calificación y verificación de capac Técnica, de contratación y facturación anual, índices de magnitud empresaria, acreditación de la sociedad legal)

- Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con las formalidades legales del caso, o Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

7. ADJUDICACIÓN

CRITERIOS: ACEPTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE
FIRMA DE LA CONTRATA
(lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal >>>> cédula de notificación)
CONSTITUCIÓN DEL Fdo. DE Gtia. DE EJECUCIÓN DEL CONTR.

8. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

El Estado licitante puede revocar, por razones de oportunidad, un llamado a licitación después de que el oferente irrogó a su costa todos los gastos que genera presentar una oferta, sin que este último pueda reclamar derecho a reconocimiento de expensas. Es decir, en los contratos Administrativos, no existe Responsabilidad Precontractual. (Cláusula exorbitante)

9. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

JURISDICCIÓN: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CLAUSULA ARBITRAL: LAS PARTES PODRÁN CONVENIR UN TRUBUNAL ARBITRAL QUE DECIDA EN ÚNICA INSTANCIA

10. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Ante circunstancias extraordinarias anormales e imprevisibles, posteriores, y sobrevinientes a la celebración de un contrato administrativo, pero temporarias o transitorias, que alteran la ecuación económico-financiera en perjuicio del contratista, es obligación del Estado asistirlo para que pueda cumplir el contrato.
La aplicación de la Teoría de la Imprevisión en el orden público es un medio de asegurar en beneficio del interés público el cumplimiento de los contratos Administrativos. Opera como principio contractual implícito que se aplica de pleno derecho y no requiere ser pactada expresamente (arts. 16 y 17, CN; art. 1198, CC). Tampoco puede ser objeto de renuncia por parte del contratante. Se pueden pactar fórmulas de reajustes, pero nunca renunciar a la aplicación de la ley que, por lo demás, es irrenunciable.

11. TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

11.1. CONTRATO DE SUMINISTRO
PROVICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

11.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro Nacional.

11.3. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA CON FONDOS DEL CONTRATISTA (CONCESIONARIO) QUE RECUPERA SU INVERSIÓN Y OBTIENE GANANCIA A TRAVÉS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA. CONTRATO A PLAZO POR TIEMPO DETERMINADO. Ej. Concesión de corredores viales (Autopistas)

11.4. CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO, FINANCIADO POR EL CONTRATISTA (LICENCIATARIO) QUE RECUPERA SU INVERSIÓN Y OBTIENE GANANCIA A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS. (SI LA EXPLOTACIÓN ES RENTABLE EXISTE UN CANON QUE DEBE SER ABONADO POR EL CONCESIONARIO. SI LA EXPLOTACIÓN NO ES RENTABLE EL CONCESIONARIO PERCIBE UN SUBSIDIO.) (En este caso se adjudica al concesionario que solicite el menor subsidio)
EN ALGUNOS CASOS SE OBTIENE (MEDIANTE LICITACIÓN) LA LICENCIA QUE DA DERECHO A LA EXCLUSIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO). Ej. Empresas de Servicios privatizadas (Distribución de Energía, Gas, telefonía, etc.)
CONTRATOS A PLAZO POR TIEMPO DETERMINADO

11.5. CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
OTORGAMIENTO DEL USO A UN CONCESIONARIO PARA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL BIEN. Con pago de canon. CONTRATO A PLAZO POR TIEMPO DETERMINADO (Ej. PLAYAS COSTERAS, PARQUES, TERRENOS FISCALES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, ETC.)

11.6. PERMISO PRECARIO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
Idem ant. EL ESTADO PUEDE RESCINDIR EL CONTRATO SIN PREVIO AVISO NI INDEMNIZACIÓN. (Plazo incierto)

11.7. CONTRATO DE EMPRESTITO PÚBLICO
PRESTA DE DINERO AL ESTADO. DEVOLUCIÓN CON INTERESES.
BONOS, TÍTULOS, LETRAS DEL TESORO NACIONAL

11.8. CONTRATO DE CONCESIÓN DE TIERRAS Y BOSQUES FISCALES
SE OTORGA A CONCESIONARIO PARA EXPLOTACIÓN EXCLUSIVA. Con pago de canon. (Ej. Explotación petrolera / minera / pesquera / bosques)

11.9. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA:
CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PARA APOYO DEL CORREO OFICIAL. (Es un caso particular de Locación de Servicio donde el Organismo contratante es el Correo Oficial)

12. ENTES REGULADORES

Fueron creados en la década de 1990 por leyes del Congreso Nacional o decretos del Poder Ejecutivo Nacional y poseen un status jurídico diferenciado del de los Ministerios y demás dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.

La razón de esta independencia es la de asegurar la continuidad de los equipos técnicos más allá de la duración del gobierno, como forma de brindar mayor estabilidad e independencia a la hora de establecer y aplicar regulaciones.

12.1. ¿PARA QUE SE CREARON?

Los Entes Reguladores son Organismos de control estatal creados para fiscalizar la aplicación de las normas que regulan la relación usuario-empresa tras la privatización de la mayor parte de los servicios públicos (teléfonos, gas, agua, electricidad, etc.) esencialmente monopólicos.

La tarea de regular consiste primordialmente en establecer cómo se deben hacer determinadas actividades, qué está permitido y qué está prohibido. Es decir, establecer las reglas de juego que gobiernan a los actores de un sector evitando conductas anticompetitivas, monopólicas y posiciones predominantes.

12.2. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

En relación con sus capacidades y competencias, la mayoría de estas agencias goza de las siguientes misiones específicas que fueron establecidas en las normas de creación:

- **Regulatorias**: al dictar normas a las que deben someterse los sujetos de la ley;

- **Administrativas**: por controlar la prestación del servicio; es decir que ante un incumplimiento por parte de las proveedoras de servicio es el Ente Regulador quien hace valer los derechos del usuario y tiene facultades para aplicar sanciones.

- **Judiciales**: debido a que algunos entes tienen ciertas capacidades de resolución de conflictos dentro de la industria.

Además, tienen amplias atribuciones para obtener información sobre las empresas prestatarias y sus respectivas industrias.

12.3. FUNCIONES DE LOS ENTES REGULADORES

SINTÉTICAMENTE PODEMOS DECIR QUE LOS ENTES REGULADORES:

- HACEN DE ÁRBITROS MEDIANDO EN CASO DE CONFLICTOS ENTRE LAS EMPRESAS LICENCIATARIAS Y SUS CLIENTES.
- SE DEBE RECURRIR A ELLOS UNA VEZ AGOTADAS LAS POSIBILIDADES DE SER ESCUCHADOS POR LAS RESPECTIVAS EMPRESAS DE SERVICIOS.
- SUPERVISAN EL RESPETO DE LOS CUADROS TARIFARIOS VIGENTES.
- EJERCEN EL CONTRALOR DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE LAS PRESTACIONES.
- DISEÑAR Y SUPERVISAR LOS ESTÁDARES AMBIENTALES DE SEGURIDAD
- ASEGURAR LA ESTABILIDAD EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO
- CONTROLAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS MÍNIMAS Y LAS METAS DE LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN O DE LAS LICENCIAS.
- CONVOCAN AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EVALUAR MODIFICACIONES TARIFARIAS O CONDICIONES DEL SERVICIO.

12.4. ¿Quiénes Controlan a los Entes?

Son auditados principalmente por el *Congreso Nacional*, a través de dos vías:

Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y las Privatizaciones:
creada por la *Ley de Reforma del Estado (N° 23.696)*. Este organismo está compuesto por seis miembros provenientes de cada una de las Cámaras y su objetivo es seguir la aplicación de esta Ley e informar a los poderes del Estado.

Auditoría General de la Nación (AGN):
es un órgano técnico, funcionalmente autónomo dentro del área del Congreso de la Nación, que tiene como competencia el control de las privatizaciones y de los entes reguladores. Desde la Gerencia General de Entes Reguladores, audita los estados contables y la gestión. Emite informes de auditoría y dictámenes de estados contables de los entes reguladores que son luego comunicados a los propios entes, a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas –órgano bicameral que controla la AGN– y a los Ministerios que tienen a su cargo el control de la privatización de que se trate.

13. ARBITRAJE ENTRE GOBIERNOS NACIONALES Y EMPRESAS TRANSNACIONALES.
(CIADI) (CONSEJO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE INVERSIONES)

El CIADI es una filial del Banco Mundial que arbitra en los litigios entre los inversores extranjeros (CORPORACIONES TRANSNACIONALES) y los Estados nacionales. >>>SEGURIDAD JURÍDICA A LOS FLUJOS DE INVERSIONES.

Es el organismo elegido por la mayoría de las privatizadas para plantear sus demandas contra el Estado argentino.

Argentina adhirió al Ciadi a través de la ley 24.353 sancionada en septiembre de 1994. El procedimiento de arbitraje internacional del Ciadi establece lo siguiente:

1. Si no ha habido declaración expresa en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje excluye cualquier otro recurso

2. se puede recurrir al arbitraje sin exigir el agotamiento previo de las vías administrativas o judiciales nacionales

3. el Tribunal Arbitral resuelve sobre su propia competencia

4. el laudo tiene el valor de una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado condenado y se ejecuta de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieran en vigor en los tribunales en que dicha ejecución se pretenda. Este punto supone la renuncia a la jurisdicción de los tribunales locales en las controversias sometidas al Ciadi.

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE ENTES REGULADORES

Cuadro I: El Diseño de los Entes Reguladores

	ETOSS (Agua y Cloacas)	ENARGAS (Gas natural)	ENRE (Energía eléctrica)	CNT (tele-comunicaciones)
Creación Ente	Decreto 999/92	Ley 24.076 (6/1992)	Ley 24.065 (1/1992)	Decreto 1185/90
Nombramiento de los Directores (ETOSS tiene 6, y el resto tienen 5 c/u)	Jurisdicciones involucradas (Nación, Prov. de Bs. As. Y MCBA)	Presidente, con "acuerdo" (opinión) del Congreso (comisión Bicameral)		Presidente (uno es propuesto por un consejo federal formado por gobernadores)
Entidad Autárquica	Sí	Sí		Sí
Financiamiento	Suma fija cargada en la tarifa	Tasa %, sobre los ingresos de las empresas reguladas (fijada por el Ente en su presupuesto), más multas a las empresas reguladas		Tasa % sobre las emp. Reguladas, igual a 0,5% en el Decreto
Confección del presupuesto	Lo establece el ETOSS; debe ser "equilibrado"	Ente eleva presupuesto al PEN para su inclusión en el proyecto de presupuesto nacional		Idem ENARGAS y ENRE
Discusión publica del presupuesto	No	El proyecto debe publicarse para que pueda ser objetado por las partes involucradas (vgr., empresas reg.)		No (excedentes del 0,5% financian proy. oficiales de telecom. y radiodifusión)
Estabilidad del Directorio	Sí (6 años, puede existir una reelección)	Sí (5 años), puede existir reelección indefinidamente)		Sí (5 años, puede existir una reelección)
Restricciones de empleo Directores	No	No		Sí (un año)
Supervisión	Auditoría General de la Nación (Augena, interviene ex-post, depende del Congreso Nac.)	Augena		Sigena (reporta al PEN) y Augena
Especificidad legislación	Estructura tarifaria flexible; Price-cap híbrido global	Estructura Tarifaria flexible Price-cap con passthrough, global; Razonabilidad de las compras de gas		Estructura Tarifaria Rígida Price-cap indi-vidual c/servicio
Presupuesto (en millones de $), 1995	$ 6.2	$ 19	$ 13	$ 54
Otros	En el financiamiento del ETOSS, la aplicación ha sido mantener una tasa fija	Audiencias públicas; el Ente debe dictar las normas de procedimiento aplicables y sujetarse a ellas. Multas reintegradas a consumidores por el ENRE		Creación posterior a la privatización de ENTEL. Fue intervenida por el PEN en 1992 y 1995

ANEXO 2: ENTES REGULADORES

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT)

TEL: 0-800-333-0300

APARTADO POSTAL 129, CORREO CENTRAL 1000 – WAB 1000

PARAGUAY 1239. CIUDAD DE BUENOS AIRES

ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS)

TEL: 0-800-333-0200 / 4815-9229. LUNES A VIERNES DE 9 A 17 HS.

E-MAIL: ETOSSGRI@ETOSS.ORG.AR

AV. CALLAO 976/982. CIUDAD DE BUENOS AIRES

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)

TEL: 0-800-333-3000 / 0-800-444-5678. LUNES A VIERNES DE 9 A 16 HS.

PÁG. WEB: WWW.ENRE.GOV.AR

MADERO 1020, PISOS 7º, 8º, 9º Y 10º. CIUDAD DE BUENOS AIRES

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC)

TEL: 0-800-333-3344 - LUNES A VIERNES DE 8 A 18 HS.

E-MAIL: CASADELCLIENTE@CNC.GOV.AR

PÁG. WEB: WWW.CNC.GOV.AR

PERÚ 598. CIUDAD DE BUENOS AIRES

OCCOVI - ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 0-800-222-6272

AUTOPISTAS DEL SOL: 0-800-888-7273 Ó AL 45 12-8700/14

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE: 0-800-999-2185 Ó AL 4489-8200

COVIARES S.A.: 0-800-333-5560 Ó AL 4253-5926

AEC S.A.: 0-800-999-9999 Ó AL 4462-1244

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS)

TEL: 0800-333-4444/ 4325-2500

LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS.

PÁG. WEB: WWW.ENARGAS.GOV.AR

SUIPACHA 636. CIUDAD DE BUENOS AIRES